Signature Not Verified
Assinado por ALBERTO BRANDAO HENRIQUES MAIMONI em 11/12/2015 15:55:14.786 -0200

Maimoni
Advogados Associados

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – BRASÍLIA-DF.

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL, com representação no Congresso Nacional, devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral por meio da Resolução nº 22.083, de 15 de setembro de 2005, com sede e fora em Brasília (DF), SCS, Bloco 5, Loja 80, CEP 70.305-000, representado por seu Presidente Raimundo Luiz Silva Araújo, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 212.951.582-72, com fundamento no art. 103, VIII da Constituição Federal e da Lei nº 9.868, de 1999, por intermédio de seus advogados devidamente habilitados em procuração específica, vem, respeitosamente, propor uma

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (com pedido de liminar)

contra o art. 142, da Lei Federal nº 13.097 de 19 de janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 20 de janeiro de 2015 resultado da conversão da Medida Provisória nº 656, de 7 de outubro de 2014 e que alterou a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pelas razões de direito abaixo expendidas.

I - DA LEGITIMIDADE

1. Por força do art. 103, VIII da Constituição Federal, assim como do art. 2º, VIII da Lei nº 9.868, de 1999, o Partido Socialismo e Liberdade, elegeu representantes no Congresso Nacional, possuindo em seus quadros 5 deputados federais, e ostenta a legitimidade ativa universal necessária para a propositura da presente ação direta de inconstitucionalidade.

2. A presente ação é proposta respondendo a solicitação de entidades da sociedade civil que atuam em favor da saúde no país e tem por base memoriais apresentados ao Partido da lavra do **Centro Brasileiro de Estudos de Saúde – CEBES**, da **Associação Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde – AMPASA** e do **Instituto de Direito Sanitário Aplicado – IDISA**.

II - O DISPOSITIVO QUESTIONADO

1. O dispositivo legal que se aponta como inconstitucional é o art. 142 da Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, abaixo transcrito:

> *Art. 142. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:*
>
> "*Art. 23. É **permitida** a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos:*
>
> *I – doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos;*

II – pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar: a) hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada; e

b) ações e pesquisas de planejamento familiar;

III – serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social; e

IV – demais casos previstos em legislação específica."(NR)

"*Art. 53-A. Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para saúde, laboratórios de analises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem e são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros."*

2. Antes do dispositivo questionado, o capital estrangeiro tinha sua participação restrita aos planos privados de assistência à saúde, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.656 de 3 de junho de 1998, ou seja, na qualidade de ***operadora de plano***, que pode ser considerada como uma espécie de seguradora por contratar risco futuro e aleatório de doenças, diferentemente daqueles que prestam serviços de assistência à saúde. Como afirma Luiz Guilherme de Andrade Loureiro[1], *na prática, os contratos de seguro saúde e os planos de seguro de assistência à saúde são equivalentes, a eles se aplicando, sem diferenciação, as normas previstas na lei 9656/98.*

[1] *In Seguro Saúde – Editora Lejus2000.*

[2] CLÈVE, Clèmerson Merlin. **A eficácia dos direitos fundamentais sociais**. Revista Crítica Jurídica, Curitiba: UNIBRASIL, n. 22, p. 17-29, 2003.

3. Das permissões da Lei 8.080, o capital estrangeiro, de uma exceção, é a regra e pode estar presente no seguinte:

1. nas doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos;
2. nos serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social (exceção trazida pela MP 656);
3. nas operadoras de planos privados de assistência à saúde (*ex vi* da Lei 9.656, de 1998, permite que estrangeiros possam ter participação ou o controle das operadoras, assim como que as operadoras de planos de saúde, por sua vez, possuam rede própria hospitalar, médica e/ou odontológica para exercer as suas funções);
4. nas ações e pesquisa de planejamento familiar, sem a fiscalização e controle pelo órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde, *ex vi* do art. 7º da lei Federal 9.263, de 1996;
5. nos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem (exceção trazida pela MP 656); e
6. nas atividades de pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar: a) hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada (inclusões pela MP 656).

3. A Câmara dos Deputados aprovou em 17/12/2014, a Medida Provisória nº 656 de 2014, encaminhando-a ao Poder Executivo Federal como o Projeto de Lei de Conversão nº 18 de 2004. A Medida Provisória nº 656, de 2014, editada pela Presidente da República, inicialmente pretendia reajustar a tabela do Imposto de Renda e outras matérias civis tributárias e financeiras, mas foi aprovada com mais de 30 outros assuntos sem pertinência com o texto original.

4. Convertida a Medida Provisória na Lei nº 13.097, de 2015 foi autorizada a entrada de capital estrangeiro e de empresas estrangeiras no setor de saúde, ampliando exponencialmente e de modo que um ou outra, já não mais uma exceção, poderão instalar ou operar hospitais (inclusive filantrópicos) e clínicas, além de executar ações e serviços de saúde de qualquer natureza, o que é reforçado pela introdução do novel art. 53-A, na Lei Federal.

II - ART. 142 DA LEI 13.097- DA OFENSA AO ART. 2º DA CF/88 – CONTRABANDO LEGISLATIVO

1. O dispositivo aqui questionado foi inserido na Medida Provisória nº 656 (MP 656) de forma imprópria e clandestina. A ampla abertura ao capital estrangeiro ao financiamento da assistência à saúde não tem qualquer correlação com o tema originário do diploma legislativo exclusivo do Poder Executivo.

2. A MP foi transformada numa colcha de retalhos com a inclusão de trinta e dois temas alheios à proposta: inclusive matérias que não têm qualquer pertinência com tributação, tais como, um novo parcelamento das dívidas de clubes de futebol com a União e de empresas de radiodifusão; o programa de estímulo à aviação regional; a autorização para a construção de um aeroporto privado na região metropolitana de São Paulo, licitação pública, estatuto do servidor público federal, Anvisa, autorização para o capital estrangeiro investir no setor da saúde; entre outros.

3. Pela exposição de motivos da Presidência da República, publicado no D.O. de 08/10/2014, verifica-se, *litteris*, os assuntos tratados e, segundo o Executivo, albergados com urgência e relevância justificadores da excepcional medida provisória:

> *"(...) Projeto de Medida Provisória que prorroga benefícios, reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre a receita*

decorrente da venda e na importação de partes utilizadas em aerogeradores, dispõe sobre a devolução ao exterior ou destruição de mercadoria estrangeira cuja importação não seja autorizada, dispõe sobre procedimentos referentes à averbação e ao registro na matrícula de bens imóveis, altera a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, dispõe sobre a Letra Imobiliária Garantida (LIG), dispõe sobre a delegação da inscrição em dívida ativa distrital ou municipal e execução fiscal dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural cobrados pelos municípios ou pelo Distrito Federal, nos termos do art. 153, §4º, III, da Constituição Federal, e dá outras disposições".

4. Não consta do texto o gravíssimo assunto inserido no art. 142 da MP convertida na Lei 13.097/2015.

5. A inclusão pelo Congresso Nacional de matéria estranha ao desígnio original da proposta normativa fere o princípio constitucional da separação dos poderes, esculpido no art. 2º da CF/88, configurando, pelo desvio, usurpação da atribuição exclusiva da Presidência da República de propor medidas provisórias.

6. O financiamento estrangeiro da assistência à saúde é matéria completamente diversa ao assunto legislado.

7. O Congresso Nacional regulamentou diretamente a Constituição Federal através de uma emenda extravagante (a chamada "emenda jabuti" ou o chamado "contrabando legislativo") a uma MP.

8. Não se cuida, portanto, de uma mera emenda à uma MP, mas de uma "superemenda" que normatizou a exceção restritiva do art. 199, §3º da CF/88. Ou seja: a Constituição Federal foi regulamentada por uma "emenda jabuti".

9. Nítido que o Congresso Nacional atuou fora dos limites de sua competência legislativa no concernente ao processo de conversão de MP, burlando o

regime jurídico-constitucional da MP. O art. 61 da CF/88 fixa modalidade de "reserva legislativa", espaço excepcional destinado ao Poder Executivo e protegido da interferência do Poder Legislativo. Este, excepcionalmente, cede lugar de sua função típica legiferante ao Executivo e passa, na apreciação da Lei de conversão, a estar vinculado aos temas relevantes e urgentes da Medida Provisória.

10. A emenda desrespeita o devido processo legislativo, estabelecido nos art. 60 e seguintes da CF/88.

11. Eis que há significativa diferença no trâmite da MP e de um Projeto de Lei (PL).

12. No processo legislativo para aprovação de uma lei observa-se maior grau de discussão e de amadurecimento da matéria, com a oitiva de várias visões sobre o tema, seja através dos parlamentares, quando discutem o projeto nas inúmeras comissões e no Plenário - os PL precisam passar pelas comissões ligadas ao tema do qual tratam e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de ir ao Plenário -, seja por intermédio da sociedade civil, quando internamente discute nas audiências públicas, ou externamente discute nas mídias e meios de comunicação. Um PL não tem data para ser votado, salvo a exceção da adoção do regime de urgência, quando texto precisa ser votado em 45 dias, em tese, passando a trancar a pauta do Plenário.

13. Já a MP possui trâmite mais acelerado - exatamente porque possui, em hipótese, os justificadores critérios de relevância e urgência. Assim, quando chega ao Congresso, a MP recebe um parecer de um pequeno grupo de parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, seguindo para análise de ambas as Casas legislativas. Caso aprovada, a MP se transforma em lei. Se rejeitada, perde o efeito que usufruiu enquanto vigeu. Diferente do PL, a MP tem prazo de 60 dias, renováveis por outros 60, para ser definitivamente apreciada. Decorrido esse prazo, se não for submetido aos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o texto perde o efeito de lei.

14. O art. 142 da Lei 13.097, assunto de amplíssima repercussão negativa no sistema de saúde nacional, sorrateiramente incluído e aprovado, cerceia o necessário e completo processo legislativo, tratando com urgente rapidez e sem o crivo de um rematado processo, um assunto excepcional que a CF/88 desejou fosse mais completamente discutido e resolvido.

15. O art. 142 da Lei 13.097, principalmente porque advindo de emenda "jabuti", significa burla aos critérios justificadores da MP - a relevância e a urgência - critérios esses que apenas o Poder Executivo poderia indicar originalmente numa MP.

16. Todas estas questões foram discutidas recentemente pelo STF na ADI 5.127, Rel. a Ministra Rosa Weber. O STF julgou a ação decidindo que o Congresso Nacional não pode incluir, em medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo, emendas parlamentares que não tenham pertinência temática com a norma.

17. Para a relatora, exatamente como aqui alegado, *"o 'contrabando legislativo' não denota mera inobservância de forma, mas um procedimento antidemocrático, em que se subtrai do debate legislativo – intencionalmente ou não – a discussão sobre normas que irão regular a vida em sociedade"*. Destacou o STF que a emenda, ao seguir o rito da conversão de MP, impediu que os dispositivos questionados fossem analisados por comissões temáticas, fossem objeto de audiências públicas e que fosse debatido e refletido de forma mais aprofundada.

18. Ante a invasão de competência constitucionalmente atribuída a outra esfera de Poder, houve, pelo Poder Legislativo, ofensa ao princípio da separação dos poderes, inserido no artigo 2º da CF/88, assim como ofensa direta ao devido processo legislativo do art. 60 e seguintes da CF/88.

III – ART. 142 DA LEI 13.097 - DA OFENSA AO ART. 199 § 3º DA CF

1. Diz a Constituição Federal:

> *Art. 199 § 3º "É **vedada** a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei";*

2. A afronta à Carta Constitucional, que vedou ao capital externos às atividades de assistência à saúde, já começa pelo título do capítulo XVII da Lei nº 13.097/2015: CAPÍTULO XVII - DA ABERTURA AO CAPITAL ESTRANGEIRO NA OFERTA DE SERVIÇOS À SAÚDE.

3. A regra relativa ao financiamento das atividades de assistência à saúde é a *vedação*, com as ressalvas da lei. Exceções criadas por lei devem ser limitadas, excepcionais e não podem significar a abertura escancarada, sem limites, ao capital estrangeiro de todos os setores das atividades de assistência à saúde, conforme preceituam as alterações feitas na Lei nº 8.080/1990.

4. Ademais, não se pode conceber que o legislador infraconstitucional esteja completamente livre para estabelecer tais exceções. O legislador ordinário deve apenas explicitar o que já se encontra implícito na Carta, restando evidente que só serão constitucionais as exceções que estejam em conformidade com a intenção da norma Constitucional; ou seja, só são possíveis específicas exceções que, comprovadamente, contribuam para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e ao mesmo tempo não consubstanciem-se em ofensa à soberania nacional sob o aspecto sanitário.

5. O que se nota nitidamente é que o art. 142 da Lei nº 13.097/2015 torna a vedação constitucional letra morta por admitir que o capital estrangeiro se instale em todas as áreas compreendidas pela assistência à saúde. Inclui ainda para o capital estrangeiro o planejamento familiar como regra e sem a mínima regulamentação prévia, autorização, análise ou qualquer outro procedimento necessário a preservação da regra geral de vedação. Exceção não pode virar a regra sob pena de deixar de ser

exceção e passar a ser a regra. Hoje passou a ser regra o financiamento das atividades de saúde pelo capital estrangeiro. E o que era exceção passou a nortear todo o sistema de saúde.

6. A simples dicção dos casos do art. 23, da Lei nº 8.080 de 1991, com a alteração proposta na Lei 13.097/2015, não esconde a amplitude do que, agora, se pretende permitir ao capital estrangeiro, a atuação na assistência à saúde por meio de:

> *a) hospitalares gerais ou especializados, incluindo a filantropia;*
>
> *b) clínica geral, especializada, policlínica;*
>
> *c) laboratórios de genética humana;*
>
> *d) produção e fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde;*
>
> *e) laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnósticos por imagem.*

7. Constata-se que todas as atividades de assistência à saúde estão previstas no referido artigo da Lei 13.097/2015, restando a pergunta: o que está vedado? Qual é a exceção à regra de vedação constitucional? A Constituição *não permite a participação de empresas e do capital externo na saúde,* mas o próprio título do capítulo, bem como a redação do *caput* do art. 23, da Lei nº 8.080/1990, alterado, abre a saúde ao capital estrangeiro e às empresas estrangeiras sem restrições, ignorando o texto constitucional. Após a Lei 13.097, não restou nada do art. 199, §3º da CF/88. A redação *salvo nos casos previstos em lei* é de positivação e não de negativa, conforme determina a Constituição ao vedar a participação estrangeira na saúde. O legislador ordinário, exercendo uma tal abrangência normativa que não possui, *acabou por eliminar a regra constitucional de vedação da participação do capital estrangeiro na assistência à saúde*.

8. Cumpre denunciar a supressão, no Projeto de Lei de Conversão, do § 1º do atual art. 23 da Lei 8.080 de 1990, a demonstrar a real intenção de abrangência da abertura do sistema de saúde ao capital estrangeiro:

> *Art. 23. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.*
>
> *§ 1° Em qualquer caso é obrigatória a **autorização** do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.*

9. Vale dizer, as empresas estrangeiras e o capital externo na saúde sequer estarão sujeitas à autorização e fiscalização do SUS! Estarão livres para atuar conforme seus interesses e não de acordo com as necessidades de saúde da população brasileira.

10. Importante lembrar que não há precedente de exceção à regra geral prevista na Constituição, exceto a prevista na atual redação do art. 23 da Lei nº 8.080 de 1990, para a saúde pública. Já na saúde privada, a **Lei nº 9.656, de 1998**, que dispõe sobre planos de saúde, também criou uma exceção à regra geral constitucional de vedação de capital estrangeiro na saúde, ao permitir no § 3º, do art. 1º, essa participação para operar somente planos privados.

> § 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.

11. Os planos de saúde se inserem no campo do seguro privado, tanto que antes da criação da Agencia Nacional de Saúde estava sob a supervisão da SUSEP – Superintendência do Seguro Privado. Sua finalidade é garantir mediante pagamento prévio, evento aleatório e futuro. O cidadão paga um valor mensal para cobertura de evento que poderá ou não ocorrer. Não são elas, operadoras de planos privados de assistência à saúde, prestadoras de assistência à saúde, conforme a assistência está definida no art. 20 da Lei nº 8.080 de 1990; porquanto **não executam ações e serviços de saúde diretamente**, são financiadores da garantia do risco eventual e futuro. Contudo, sujeitam-se à regulamentação, fiscalização e controle público nos termos do art. 197 da Constituição que trata como de relevância pública todas as ações e serviços de saúde públicos ou privados.

12. A regra constitucional acima transcrita resulta de uma opção política-constitucional do povo brasileiro que qualificou as ações e serviços públicos de saúde como direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF) e como de relevância pública (art. 197 da CF) de modo a merecer a regulamentação, fiscalização e controle pelo Estado; e, portanto, não permitindo a participação, direta ou indireta, de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, como uma estratégia de segurança sanitária.

13. Os casos de participação de empresas ou do capital estrangeiro deve se constituir em exceção visando ao atendimento das reais necessidades de desenvolvimento da assistência à saúde no país e nunca no sentido de investimento e lucro de forma pura e simples.

14. A expressão final do §3º do art. 199 – *salvo nos casos previstos em lei* – estabelece exceção específica ou restritiva. Essas exceções legais devem constar de lista restritiva ou rol exaustivo e justificadas com a demonstração do interesse da saúde pelos valores e princípios já colacionados na Carta constitucional. Antes da abertura, seria essencial a análise e o planejamento dos itens em que constate a

necessidade do capital estrangeiro, o que poderia ser efetuado no Conselho Nacional de Saúde ou através do devido processo legislativo, conforme antes demonstrado.

15. De qualquer modo, não podem as exceções, em nenhuma hipótese, inviabilizar ou mesmo criar qualquer empecilho para a progressiva consolidação do Sistema Único e Público de Saúde porque é um valor que, exige a Constituição Federal, seja prospectado. E a Lei 13.067 não só não aplica o princípio-regra, como milita em favor da inviabilização do SUS. Para o caso, em primeiro lugar a assistência à saúde pública, depois a privada nacional e, por fim e excepcionalmente em casos específicos, a assistência por capital estrangeiro.

III – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL

1. O direito à saúde é um direito fundamental, qualificado pela Constituição Federal como de relevância Pública (art. 197). Tal qualificação alça a saúde a uma posição diferenciada, garantindo-lhe natureza essencialmente pública e impondo intensa participação do Estado. Nesse sentido, mesmo quando a prestação se realiza por meio de particulares, o Estado deve atuar de forma contundente, dado que tais serviços continuam apresentando natureza pública, conforme entendimento consolidado pelo STF (ADINs 1007 e 1266, de 2005).

2. Ocorre que no atual marco constitucional a responsabilidade do Estado não se resume a exercer o controle sobre a atividade privada. Resta evidente, que apesar de possibilitar a exploração dos serviços de saúde pela iniciativa privada (art. 199), sempre sob constante regulamentação (art. 197), o Constituinte não deixou qualquer espaço para dúvidas quanto ao fato de que o Estado tem como uma de suas responsabilidades mais fundamentais a consolidação de um Sistema **Público** e Único de Saúde. Conforme disposição constitucional, tal Sistema deve garantir acesso universal e igualitário. **No Brasil, portanto, a garantia do Direito à Saúde passa,**

fundamentalmente, pela consolidação desse Sistema. O que se faz, necessariamente, de modo progressivo e gradual:

> Além disso, esses direitos são insuscetíveis de realização integral (o horizonte é sempre infinito), pois o seu cumprimento implica uma caminhada progressiva sempre dependente do ambiente social no qual se inserem, do grau de riqueza da sociedade e da eficiência e elasticidade dos mecanismos de expropriação (da sociedade, pelo Estado) e de alocação (justiça distributiva) de recursos. (CLÈVE, 2003, p. 21)[2]

3. Nesse sentido, todas as decisões políticas do setor saúde devem ser submetidas a esse crivo, com o fim de que se possa sempre verificar se estamos a nos conduzir na trajetória que tem como ponto de chegada o estabelecimento de um Sistema Público capaz de atender às necessidades da população.

4. No caso da Lei nº 13.097/15, é evidente a opção por outra trajetória. Ao permitir a participação do capital estrangeiro, sem restrições, abandona-se, definitivamente, a proposta constitucional para a saúde, desenhando-se um curso no qual o espaço do setor público caminha, inevitavelmente, para uma extrema redução.

5. Ora é evidente que com a presença do capital estrangeiro a consequência natural é ampliação do espaço do setor privado na saúde. Essa conclusão não pode sequer se questionada, visto que na justificativa enviada junto à emenda o Deputado Manoel Júnior deixa claro que a abertura busca reorientar a rota da política de saúde no Brasil garantindo o acesso à saúde, predominantemente, via mercado, *in verbis:*

> Também é notória a dificuldade do Sistema Único de Saúde (SUS) de desempenhar suas funções no atendimento da saúde

[2] CLÈVE, Clèmerson Merlin. **A eficácia dos direitos fundamentais sociais**. Revista Crítica Jurídica, Curitiba: UNIBRASIL, n. 22, p. 17-29, 2003.

> da população, restando, portanto, à iniciativa privada sanar esta deficiência.

6. Esse tipo de argumento para justificar a necessidade da presença do capital estrangeiro mostra-se absurdo e carecedor de qualquer sustentação. Do ponto de vista jurídico o que se está a defender é que o Estado estaria desobrigado a cumprir suas responsabilidades constitucionais em razão do fato de não ter atuado no sentido de cumpri-las.

7. Ora, ao afirmar que é preciso fortalecer o setor privado porque o Sistema Único de Saúde tem dificuldades de desempenhar suas funções, deve-se considerar que tais dificuldades decorrem, exclusivamente, das opções políticas (omissões) que não buscaram cumprir as determinações da Constituição. Não há outra possibilidade para as origens das dificuldades do SUS. Nesse sentido cabe lembrar, por exemplo, que desde seu início o Sistema foi subfinanciado.

8. O professor Mário Scheffer, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (DMP/FM/USP) e membro da Comissão de Política, Planejamento e Gestão em Saúde da Abrasco, em artigo[3] publicado na edição de abril da *Cadernos de Saúde Pública*, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), traça o cenário mais provável pós edição da Lei 13.097 e o "estrago" que o capital estrangeiro poderá ocasionar à saúde brasileira. Segundo ele:

> Para além da controvérsia judicial, a constitucionalização do subfinanciamento público combinada com a abertura irrestrita à participação do capital estrangeiro na saúde deverá impulsionar a privatização, na medida em que lideranças do setor privado afirmam seus objetivos imediatos de expandir a capacidade instalada de leitos e serviços para clientes de planos de saúde. (...)

[3] *In*: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2015000400663&lng=en&nrm=iso&tlng=pt - consulta em 08 de agosto de 2015.

Em meio a uma série de orientações e inações que têm por resultado o desmonte do SUS, a ampla abertura do sistema de saúde ao capital estrangeiro foi uma medida tomada sem que suas reais motivações tenham sido anunciadas, e sem que suas consequências tenham sido discutidas abertamente pelo Congresso Nacional ou avaliadas pelos fóruns de participação social.

Trata-se de vitória da coalizão de interesses de hospitais privados, empresas farmacêuticas e operadoras de planos de saúde que, além da defesa do capital estrangeiro, pretendem ampliar a participação do setor privado na formulação das políticas nacionais de saúde, expandir o mercado privado e obter desonerações e reduções tributárias. (…)

Com volatilidade e vocação especulativa, investimentos estrangeiros escolherão leitos, exames e procedimentos que geram altos retornos financeiros, principalmente serviços baseados em valores e preferências particulares, e que praticam a seleção adversa, afastando-se do atendimento a populações que vivem em áreas distantes de recursos assistenciais, do atendimento a idosos, crônicos graves, portadores de transtornos mentais e outros pacientes que demandam atenção contínua.

A expansão de rede privada com essas características fará aumentar a individualização das demandas, os pagamentos diretos em clínicas populares e o consumo de planos de saúde baratos no preço mas com armadilhas contratuais e sérias restrições de coberturas. Mais uma vez o SUS, o fundo público, será utilizado como fiador e resseguro das operações privadas.

À proporção que gastos privados substituem as despesas públicas, aumentam os obstáculos para a justiça e a equidade. Sempre que prestadores privados têm garantida a venda de seus serviços por produção, sem compromisso com os

> resultados de saúde, os riscos de desperdício de recursos e explosão dos custos do sistema de saúde são enormes.
>
> Capitais que buscam caminhos de valorização dificilmente terão compromissos com necessidades de saúde, o que requer políticas voltadas à redução de adoecimentos e mortes, com atuação sobre os determinantes sociais da saúde.
>
> O sistema universal, o sistema único para pobres e ricos, baseado na saúde como direito, na redistribuição da riqueza, financiado por toda a sociedade por meio de impostos e contribuições sociais, cede, assim, espaço ao sistema segmentado, incapaz de assegurar o acesso a todos os níveis de atenção, em todas as regiões, inclusive nos vazios sanitários e para populações vulneráveis e negligenciadas, onde e para quem o setor privado não tem interesse em ofertar serviços.

9. O fato, portanto, é que a Lei nº 13.097/15 busca traçar nova rota para a política de saúde no Brasil, contudo em evidente afronta à proposta constitucional e ao texto prévio da Lei 8.080/1990 que regulamentou a saúde no país, promovendo incontestável retrocesso, em concordância com o que foi pontuado pelo jurista italiano Pallieri em 1963:

> É inconstitucional qualquer lei que disponha em contrário ao que a Constituição emana e, uma vez dada execução à norma constitucional, o legislador ordinário está terminantemente proibido de contribuir para retornar a uma situação de ausência ou insuficiência de regulamentação infraconstitucional, revogando a lei antes editada. Estaria, nesta elaboração, o princípio da proibição do retrocesso social.

10. Nesse sentido, cabe lembrar que o STF tem consolidado firme jurisprudência nos sentido de rechaçar qualquer medida do poder público que seja

regressiva sob a perspectiva dos direitos sociais. Discorrendo sobre esse ponto o Ministro Celso de Mello (AG.REG. NO RE COM AGRAVO 745.745) aponta que:

> O *princípio da proibição do retrocesso* **em tema de direitos fundamentais** de caráter social, **impede que sejam desconstituídas** as conquistas **já alcançadas** pelo cidadão **ou** pela formação social em que ele vive [...] **Na realidade**, **a cláusula que proíbe o retrocesso** em matéria social **traduz**, *no processo de sua concretização*, **verdadeira dimensão negativa** pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional (**como** o direito à saúde), **impedindo**, *em consequência*, **que os níveis** de concretização dessas prerrogativas, **uma vez atingidos**, venham a ser reduzidos **ou** suprimidos, **exceto** na hipótese – *de todo inocorrente na espécie* – **em que políticas compensatórias** venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais.

IV - CONCLUSÕES

1. O domínio pelo capital estrangeiro na saúde brasileira inviabiliza o projeto de um Sistema Único de Saúde de qualidade e em quantidade suficiente às necessidades da população brasileira, tendo em vista que a ampliação de espaço para o mercado privado, em especial o estrangeiro, poderá enfraquecer os investimentos públicos, já bastante insuficientes para o atendimento da população, em especial com a PEC 358/2014 que constitucionaliza o subfinanciamento da saúde. De fato parece haver um casamento entre a PEC 358 votada em dezembro de 2014 e a Lei 13.097/2015, votada também em dezembro. Insuficiência de um lado, pode, de outro, significar amplitude de mercado para o investimento estrangeiro, sem regulação e sem demonstração de sua necessidade.

2. Nesse sentido a proposta transforma a saúde, fundamentalmente, em um bem comerciável, sujeito a regras de consumo, ao qual somente quem tem dinheiro tem acesso.

3. Com a possibilidade do capital estrangeiro ou empresas estrangeiras possuírem hospitais e clínicas - inclusive filantrópicas, podendo atuar de forma complementar no SUS - ocorrerá uma apropriação do fundo público brasileiro, através do orçamento próprio da saúde e de financiamentos vantajosos através do BNDES, por exemplo, podendo representar mais uma saída do que entrada de capital no Brasil; situação essa que representa mais um passo rumo à privatização e desmonte do SUS. Ainda a participação estrangeira na área da filantropia pode ser altamente deletéria, tendo em vista as imunidades e isenções tributárias de que gozam as entidades filantrópicas no nosso país; ela poderá ocupar o espaço das santas casas, já bastante consumidas, e dominar o terceiro setor, criando organizações sociais que podem gerir serviços públicos. As exceções de abertura do capital estrangeiro na saúde devem ser cuidadosamente analisadas em razão do bem protegido e dos altos lucros que podem gerar.

4. Esse é o caminho que atende aos interesses do grande capital internacional, que voltou seus olhos à possibilidade de ampliar seus lucros, inicialmente com a venda de planos e seguros baratos, mas com uma cobertura de serviços extremamente limitada, que não garante o direito à saúde e que agora se aproveita para se apropriar de fundos públicos. Não foi isso que o povo brasileiro aspirou em seu texto constitucional de 1988, nem o que aspira hoje. É desejo nacional que a saúde permaneça como direito de e para todos, com qualidade.

5. O que se percebe, portanto, é que tal medida constitui-se em verdadeiro retrocesso. Ora basta ter em mente a real proposta Constitucional para a aérea da saúde, para perceber que a atual legislação conduz a política de saúde na direção contrária. Está mais do que claro que o constituinte optou por responsabilizar o Estado pela consolidação de um sistema de saúde público com a capacidade de atender a

necessidade de saúde de TODA a população. Não há, portanto, qualquer possibilidade de defender a constitucionalidade de medidas, como a agora questionada, que promovam o fortalecimento da presença do setor privado na área da saúde. Há nesse sentido evidente ofensa ao princípio da vedação de retrocesso.

6. A quem interessa a abertura do capital estrangeiro na saúde brasileira, aprovada de forma inconstitucional, em regime de urgência de uma medida provisória, sem discussão social e no apagar das luzes do final de ano e mandato legislativo – dia 17 de dezembro de 2014? Somente àqueles que não querem que o SUS dê certo. São os que têm medo do sucesso do SUS, impedindo-o de todas as maneiras de ser um sistema de justiça social. E quem tem medo do sucesso do SUS são os que pretendem maiores lucros na sua exploração econômica.

7. Tendo em vista o contexto apresentando, têm-se em vista que o capital estrangeiro não se instalará no país para a melhoria da saúde para os 150 milhões de pessoas que dependem com exclusividade dos serviços públicos de saúde.

V - DO PEDIDO DE LIMINAR

1. A concessão de medida liminar é essencial para preservar a ordem jurídica violada pelo art. 142 da Lei 13.097/2015 que ignora o § 3º do art. 199 da Constituição Federal que veda a participação de empresa e investimento estrangeiro na assistência à saúde, salvo exceções previstas em lei.

2. A não suspensão do disposto no art. 142 resultará na cristalização da violação constitucional, tendo em vista a dificuldade de reversão de investimentos em hospitais, laboratórios e outros serviços de saúde, se consumados. Como poderia uma empresa estrangeira, proprietária de um hospital no país, deixar de sê-lo, se a presente ação for julgada procedente depois de vários anos? Haveria, com certeza, graves dificuldades em razão do patrimônio investido e da própria assistência à saúde que

poderá ser prejudicada caso um serviço de saúde venha a ser fechado. Fatalmente em situações como esta, o Poder Público poderá ter que assumir serviços de saúde nem sempre em acordo com suas políticas públicas, seu planejamento público. O risco de cristalização da violação constitucional é bastante alto se a liminar não for concedida. Mesmo que no mérito venha a ser reconhecida a inconstitucionalidade requerida, ela poderá ser inócua pelos efeitos do tempo que certamente cristalizará situações inconstitucionais.

3. Há forte presença do *fumus boni iuris*, havendo a verossimilhança das alegações, conforme antes demonstrado, assim como do *periculum in mora*, ante a possibilidade latente de danos irreparáveis, incomensuráveis à todo o SUS e à saúde pública nacional, autorizando-se ao STF, nos termos do art. 10 da Lei 9.868, a concessão de medida cautelar para a imediata suspensão dos efeitos do art. 142 da Lei nº 13.097, de 2015.

VI. DOS PEDIDOS

1. Em razão do exposto, e acreditando que a plausibilidade do direito está fartamente demonstrada, bem como o prejuízo a todo o povo brasileiro, mormente no tocante à edição do art. 142 da Le 13.097, em flagrante afronta formal à Constituição Federal requer:

a. A procedência da presente ação direta, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade da art. 142 da Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015;

b. A concessão de medida cautelar, nos moldes do art. 10 da Lei 9.868, e aplicando-se o rito do art. 12 da mesma lei, para suspender os efeitos de vigência do art. 142 da Lei 13.097, de 2015, até julgamento final da presente ADI;

c. Dadas a relevância e a repercussão nacional da matéria, que sejam adotadas as providências do art. 9º, §1º da Lei 9.868, requerendo-se a realização de audiências públicas no âmbito deste E.STF para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria e requisitando-se, se for o caso, informações adicionais e designando-se perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão;

d. A solicitação de informações à Presidência da República, na pessoa de seu mandatário;

e. Depois de colhidas as informações necessárias seja citada a Advocacia-Geral da União, por seu representante, e ouvida a Procuradoria-Geral da República, bem como apreciada a medida cautelar, requer-se o julgamento, ao final, pela procedência da presente ação direita de inconstitucionalidade.

f. Por serem de valor inestimável os bens jurídicos em discussão, dá-se à causa o valor de R$1.000,00.

Termos em que, Pede Deferimento.

Brasília (DF), 11 de dezembro de 2015.

ANDRÉ MAIMONI
OAB/DF nº 29.498

ALBERTO MAIMONI
OAB/DF nº 21.144

ALVARO MAIMONI
OAB/DF nº. 18.391